

HABEAS CORPUS 276.580 GOIÁS

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : CHARLES AUGUSTO DE JESUS
IMPTE.(S) : WALLAS PIRES DE CASTRO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado por Wallas Pires de Castro, em favor de Charles Augusto de Jesus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 3.240.408/GO, assim ementado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, o agravante é reincidente, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, *a reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a*

exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto (HC n. 229.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013). Desse modo, qualquer tipo de reincidência impede a aplicação do referido benefício.

4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além da reincidência, houve a apreensão de quantidade razoável de droga (961g de cocaína), de natureza altamente deletéria (cocaína), inclusive utilizada na exasperação da pena-base, o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

5. Agravo regimental não provido." (eDOC 12)

Narra o impetrante que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput*, e § 4º, da Lei 11.343/2006).

Buscando redimensionamento da pena, a defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido de redimensionamento da pena foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (eDOC 5)

O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal estadual e o subsequente agravo foi conhecido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao recurso especial (eDOC 10). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 13).

Nesta Corte, o impetrante alega, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita.

No mais, insiste na tese de que há impropriedade na dosimetria da pena, consistente no afastamento do tráfico privilegiado em razão de condenação anterior pela prática de crime culposos de trânsito.

Entende que há *bis in idem*, pois o Tribunal estadual exasperou a pena-base e afastou a redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com fundamento na quantidade e na natureza das drogas apreendidas.

Afirma, ainda, que o regime fechado foi imposto sem fundamentação idônea.

Dessa forma, requer a concessão da ordem de *habeas corpus* para redimensionar a pena, com a imposição de regime prisional menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.

Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, **o que é, em parte, o caso dos autos.**

Inicialmente, sobre a alegação referente à nulidade da busca pessoal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pela Corte estadual, de modo que a análise por esta Corte resultaria em **dupla supressão de instância**.

Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não

é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.

Quanto à aplicação do redutor, assiste razão à parte. Vejam-se, a propósito, trechos do voto condutor do acórdão ora impugnado:

“Busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

No ponto, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 301/302):

Avançando para o ponto central da insurgência — a não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o chamado tráfico privilegiado —, verifico que o juízo agiu com acerto, não havendo qualquer traço de teratologia ou equívoco judicial a esse respeito.

De fato, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais constante nos autos originários (mov. 115 – processo nº 5421525-50.2024), à época da prolação da sentença condenatória, o revisionando possuía, contra si, duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, a saber: (i) processo nº 0088473-37.2018, pelo crime previsto no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) processo nº 5137463-95.2023, referente à contravenção penal descrita no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ambas as penas encontram-se em execução nos autos nº 7000027-94.2022.8.09.0120 (SEEU).

Considerando-se que o revisionando ostenta reincidência pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro — conforme se extrai dos autos nº 0088473-37.2018 —, conclui-se que ele não preenche os

requisitos legais para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Como é cediço, o redutor previsto no § 4º do art. 33 da referida norma exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e tampouco integre organização criminosa.

[...]

No presente caso, diante da reincidência devidamente comprovada, o revisionando não satisfaz tais exigências, motivo pelo qual não faz jus à causa especial de diminuição de pena.

[...]

De fato, ainda que o crime ensejador da reincidência tenha natureza culposa — isto é, não configure reincidência específica —, tal circunstância não afasta a vedação legal imposta ao reconhecimento do redutor, porquanto, conforme acima explicitado, a norma exige, de forma cumulativa, a primariedade e os demais requisitos, o que, a toda evidência, não se verifica nos presentes autos.

Assim, ainda que o revisionando alegue a apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes, a reincidência ora constatada constitui, por si só, óbice intransponível à concessão do benefício.

Diante de tais considerações, não se vislumbra erro judiciário ou ilegalidade na aplicação da pena que justifique a revisão pretendida, a qual, portanto, não deve ser acolhida.

De fato, ainda que tenha sido interposto recurso de apelação, esta Corte de Justiça, por meio de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo revisionando, inclusive quanto ao ponto ora objeto de insurgência. Na ocasião, ressaltou-se expressamente que a reincidência, ainda que não

específica, constitui óbice à concessão do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

(...)

No presente caso, o agravante é reincidente, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, não foram considerados os maus antecedentes e a quantidade da droga apreendida para afastar o referido benefício, apenas a reincidência do envolvido.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, *fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito* – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.

(...)

No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, houve a apreensão de quantidade razoável de droga (961g de cocaína), de natureza altamente deletéria (cocaína), inclusive utilizada na exasperação da pena-base, o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: AgRg no HC n. 826.067/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023; AgRg no HC n. 834.057/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023; AgRg no HC n. 808.479/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023; AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; AgRg

no HC n. 810.040/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg no HC n. 818.194/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.” (eDOC. 13)

Para a concessão do redutor o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. *Comentários à Lei de Drogas*. 2016. p. 50).

Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, entendo que o paciente possui o direito à redução, uma vez que a reincidência, que motivou o afastamento da redutora em questão, se deu pela prática de crime culposos. Além do mais, **não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa** e a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, **por si só, não são aptas a comprovar a dedicação à atividade criminosa**.

HC 276580 / GO

Nesse sentido, não obstante os argumentos do TJGO, verifico que o paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor.

Ante o exposto, **concedo a ordem de habeas corpus, de ofício**, (RISTF, art. 192), a fim de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, com a consequente redução de pena e de regime, se for o caso.

Comunique-se imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente